



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.002587/2017-77 (RJ2017/4091)

Data do julgamento: 13/08/2019

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

Acusados: XP Investimentos CCTVM S.A.
Guilherme Dias Fernandes Benchimol

Ementa: Responsabilidades da *XP Investimentos CCTVM S.A.* e do seu diretor responsável, Guilherme Dias Fernandes Benchimol, por falhas no registro e arquivamento de ordens transmitidas por clientes. Infração aos artigos 12, parágrafo único, e ao artigo 13, *caput* e parágrafo único, da ICVM nº 505/2011. Absoluções.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu, por maioria de votos, pela **absolução** da **XP Investimentos CCTVM S.A.** e do seu diretor responsável, **Guilherme Dias Fernandes Benchimol**, da acusação de infração ao art. 12, parágrafo único, e ao artigo 13, *caput* e parágrafo único, da Instrução CVM nº 505/2011.

A sessão de julgamento do presente processo foi iniciada em 04 de dezembro de 2018, ocasião em que o Diretor Relator, Henrique Balduino Machado Moreira, votou pela (i) condenação de **XP Investimentos CCTVM S.A.** à penalidade de **multa no valor de R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais) e (ii) condenação de **Guilherme Dias Fernandes Benchimol** à penalidade de **multa no valor de R\$ 100.000,00** (cem mil reais), por infração ao art. 12, parágrafo único, e ao artigo 13, *caput* e parágrafo único, da Instrução CVM nº 505/2011. Na sequência o Diretor Gustavo Machado Gonzalez pediu vista dos autos do processo.

Presente a procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Presente o advogado Otavio Yazbek, representante dos acusados.

Estavam presentes os os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e Pablo Renteria, que presidiu a Sessão de Julgamento.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.

Em 13 de agosto de 2019, na continuação da sessão de julgamento, o **Diretor Gustavo Machado Gonzalez** apresentou sua manifestação de voto por meio da qual concluiu pela **absolvição** da **XP Investimentos CCTVM S.A.** e do seu diretor responsável, **Guilherme Dias Fernandes Benchimol**, da acusação de infração ao art. 12, parágrafo único, e ao artigo 13, *caput* e parágrafo único, da Instrução CVM nº 505/2011.

O Diretor Carlos Alberto Rebello Sobrinho acompanhou o voto do Relator, Diretor Henrique Machado.

A Diretora Flávia Sant'Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, acompanharam o voto do Diretor Gustavo Gonzalez.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da continuação da sessão de julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Gustavo Machado Gonzalez, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Flávia Sant'Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 09/10/2019, às 18:23, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 10/10/2019, às 14:31, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 11/10/2019, às 17:15, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 15/10/2019, às 14:31, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 18/10/2019, às 11:29, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0856925** e o código CRC **7172E014**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0856925** and the "Código CRC" **7172E014**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.002587/2017-77
Reg. Col. nº 0968/18

Acusados: XP Investimentos CCTVM S.A.
Guilherme Dias Fernandes Benchimol

Assunto: Apurar responsabilidade por falhas no registro e arquivamento de ordens. Infração ao artigo 12, parágrafo único, e ao artigo 13, *caput* e parágrafo único, da Instrução CVM nº 505/2011.

Diretor Relator: Henrique Machado

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação” ou “área técnica”) em desfavor de XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP” ou “Corretora”) e Guilherme Dias Fernandes Benchimol (“Guilherme Benchimol”), por suposta infração ao artigo 12, parágrafo único, e ao artigo 13, *caput* e parágrafo único, da Instrução CVM nº 505, de 27 de setembro 2011¹.

2. O presente processo originou-se do Processo CVM nº RJ 2014/10099, no qual a SMI solicitou², em 13.03.2015, à Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) inspeção (“Inspeção”) junto ao referido intermediário com intuito de apurar possível prestação de serviços de consultoria pela Guia da Bolsa Agente Autônomo de Investimentos Ltda. (“Guia da Bolsa”) para clientes da XP, em desacordo com as disposições contidas na Instrução CVM nº 497, de 03 de junho de 2011 (Doc SEI nº 0250006).

¹ Art. 12. O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: I – escrito; II – telefone e outros sistemas de transmissão de voz; ou III – sistemas eletrônicos de conexões automatizadas. Parágrafo único. Todas as ordens devem ser registradas, identificando-se o horário do seu recebimento, o cliente que as tenha emitido e as condições para a sua execução.

Art. 13. O intermediário deve arquivar os registros das ordens transmitidas pelos clientes e as condições em que foram executadas, independentemente de sua forma de transmissão. Parágrafo único. O sistema de arquivamento de que trata o *caput* deve ser protegido contra adulterações e permitir a realização de auditorias e inspeções.

² Solicitação de Inspeção SMI/GME nº 6/2015 de 13.03.2015 (doc SEI nº 0250006).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II. FATOS E ACUSAÇÃO

3. Para delimitar o escopo da fiscalização, a SMI e a SFI decidiram aplicar os procedimentos de auditoria previamente acordados em três sociedades de agentes autônomos vinculadas à XP: a Guia da Bolsa Agente Autônomo de Investimentos Ltda. (“Guia da Bolsa”), a My Guidance Agentes Autônomos de Investimento Ltda. (“My Guidance”) e a RJ Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda. (“RJ”).

4. Dentre outros procedimentos de auditoria, a Inspeção deveria selecionar quatro ordens de quatro clientes de cada uma das três sociedades de agentes autônomos, de modo a examinar, ao final, os controles relacionados desde a emissão até o arquivamento de 48 ordens emitidas pelos clientes por meio exclusivamente dos canais de voz e escrita (Doc. SEI nº 0262439, p. 2-3).

5. Segundo a Acusação, no curso Inspeção teria sido possível identificar a ausência de atualização de dados cadastrais de clientes nas três sociedades de agentes autônomos e a presença de pessoas não autorizadas na sede da Guia da Bolsa (Doc. SEI nº 0262439). Tais evidências teriam ensejado a emissão de Ofícios de Alerta pela SMI para advertir referidas sociedades quanto ao regramento aplicável às circunstâncias (Doc. SEI nº 0243970; Doc. SEI nº 0265327; Doc. SEI nº 0266409 e Doc. SEI nº 0266500).

6. No tocante ao registro das ordens, a Acusação narra que a XP precisou de prazo adicional de 45 dias para apresentar os registros das ordens selecionadas pela Inspeção. Registra ainda que a XP teria deixado de encaminhar, sem justificativa, dois registros de ordens referentes ao investidor J.G.C.P. e que um dos 21 arquivos relativos às transcrições das ordens emitidas por voz não corresponderia à ordem transmitida pelo cliente (doc SEI nº 0262439 p. 40).

7. Acrescenta que sete dos 46 registros de ordem encaminhados pela Corretora teriam sido produzidos no curso da Inspeção, isto é, após a realização da operação em bolsa pelos clientes. Neste particular, a Acusação consigna que o agente autônomo teria entrado em contato com o cliente para obter a confirmação da ordem e, assim, conseguir apresentar à Inspeção evidências de que a ordem teria sido transmitida pelo cliente (0262439 p. 41).

8. De posse de tais informações, a SMI indagou a XP sobre tais ocorrências. (Doc. Sei nºs 0315649 e 0317277). Em resposta, a Corretora informou que as ordens emitidas pelo investidor J.G.C.P. não teriam sido enviadas por falha no momento da gravação da mídia entregue à CVM, juntando aos autos a comprovação das ordens (Doc. Sei nºs 0316924 e 0316925).

9. Quanto ao arquivo cuja transcrição não corresponderia a ordem emitida pelo cliente, a XP apresentou a gravação e a correspondente transcrição para substituir à ordem encaminhada anteriormente (Doc. Sei nºs 0316926 e 0316928).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

10. Com relação às ordens confirmadas após a realização das operações, a XP argumentou que tal confirmação não caracterizaria ausência de ordem prévia. Segundo alegou, o agente autônomo teria contatado os clientes para obter a comprovação de que a negociação foi previamente autorizada em razão da dificuldade de localizar as ordens no sistema de registro, dado o volume de operações. Assim, nas palavras da Corretora:

“em que pese a falha na forma de registro, a evidência apresentada demonstra que os investidores tinham plena ciência das operações e que elas foram executadas mediante prévia autorização, inexistindo irregularidade. (...)”

Não se pretende com essa explicação dizer que não houve falha no registro da ordem, nem que não há espaço para melhorias. O que a XP Investimentos quer demonstrar é que:

(i) a inconsistência se deu, tão somente, quanto à parte formal do registro da ordem - não quanto à essência. Trata-se de uma falha procedimental;

(ii) ainda que o registro seja posterior à execução da operação, os investidores de fato autorizaram as operações. Nenhum investidor foi lesado ou reclamou das informações; e

(iii) as ordens prévias não foram apresentadas simplesmente porque não houve tempo hábil para uma busca mais profunda nos registros de voz, que demanda um trabalho hercúleo.

11. Ao examinar os fatos apurados, a Acusação concluiu que, embora as confirmações posteriores possam servir para afastar indícios de execução infiel das ordens, a necessidade de contatar os clientes para obter as confirmações teria demonstrado a inadequação do sistema de registro de ordens da XP.

12. Para a área técnica, “a Instrução 505, em seus artigos 12 e 13, procuraria não somente garantir que o intermediário executasse as ordens em conformidade com o que determinou o cliente, mas também estabelecer um sistema de controle dos registros relevantes de modo a tornar possível a verificação, a qualquer momento, da compatibilidade entre ordens dadas e negócios executados”.

13. Deste modo, a obrigação imposta ao intermediário pela legislação seria a de manter um sistema de controle que permitisse a auditoria verificar se as ordens transmitidas pelos clientes foram fielmente executadas. Ademais, o art. 13 da ICVM nº 505/11 obrigaria o intermediário a arquivar os registros das ordens recebidas, com os detalhes de sua execução, de modo a possibilitar futuras verificações.

14. A SMI afirmou que a XP teria deixado de apresentar à Inspeção o registro de duas ordens, mesmo após a concessão de dilação do prazo para a apresentação, tendo enviado os correspondentes registros quase um ano depois. Deste modo, não poderia prosperar o argumento da Corretora de que as ordens não teriam sido apresentadas por falta de tempo hábil para realizar uma busca mais profunda.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

15. Sobre a questão, a SMI afirmou que *“a obrigação imposta ao intermediário seria a de manter um sistema de controle que permitisse a auditoria de que as ordens foram, de fato, executadas de acordo com os parâmetros determinados pelos investidores”*.

16. Além disso, a SMI destacou que *“sete dos 46 registros apresentados no curso da inspeção, representando mais de 15% das ordens solicitadas foram confirmações a posterior”*, falha procedimental que a própria Corretora teria admitido. Na visão da Acusação, tal falha demonstraria *“a existência de um sistema de controle de registros de ordens incompatível com o padrão exigido pela Instrução 505”*.

17. A Acusação concluiu que a ausência de reclamação pelo investidor não afastaria o comando da Instrução 505 da necessidade do *“armazenamento de todos os registros ‘de forma a permitir a realização de auditorias e inspeções’*. Trata-se assim da obrigação do intermediário de apresentar os registros, que é uma obrigação relacionada, mas apartada, da de executar as ordens conforme os registros”.

18. Diante deste contexto, a SMI concluiu que Guilherme Benchimol, diretor responsável pelo cumprimento da ICVM nº 505/11, não teria atuado com diligência suficiente para assegurar as determinações da legislação aplicável às circunstâncias.

III. RESPONSABILIDADES

19. Por tal razão, a SMI propôs a responsabilização da Corretora e de seu diretor responsável Guilherme Benchimol por infração ao disposto no artigo 12, parágrafo único, combinado com o artigo 13, *caput* e parágrafo único, da ICVM nº 505/2011.

IV. DEFESA

20. Em 01.12.2017, XP Investimentos e Guilherme Benchimol protocolaram defesa conjunta na qual alegam inicialmente que a SMI teria conduzido inspeção selecionando quarenta e oito negócios realizados por meio de apenas duas sociedades³ de agentes autônomos e não três, como afirmado na Acusação.

21. A Defesa lembra que a XP teria esclarecido que o registro das duas ordens remanescentes não teria sido encaminhado por falha de gravação e que, embora uma das

³ Conforme parágrafos 37, 117 e 131, na Tabela 2 e no Quadro 7 do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/Nº006/2016 (“Relatório de Inspeção”), bem como no Anexo ao Ofício nº 043/2016/CVM/SFI/GFE-1, de 25/05/2016, as sociedades consideradas foram: RJ Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda. e a Guia da Bolsa Agente Autônomo de Investimentos Ltda.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

transcrições originalmente enviadas não correspondesse à ordem referida, o registro correto já teria sido encaminhado à área técnica.

22. Quanto às confirmações posteriores, a Defesa ressaltou que elas resultariam de erro operacional isolado, relacionado à dificuldade de localizar os registros correspondentes em tempo hábil e que a prática pretendia minimizar os efeitos de tal erro, na medida em que permitiria comprovar de forma inequívoca a regularidade das ordens executadas. Frisou também que nenhuma das ordens teria sido executada em desacordo com as instruções ou sem o conhecimento do respectivo cliente. Com exceção de apenas sete confirmações posteriores de ordem, de uma amostra de quarenta e oito negócios, os registros de todas as ordens solicitadas pela área técnica teriam sido entregues pela XP.

23. Segundo alega, a SMI teria instaurado processo administrativo sancionador para discutir, sem qualquer ocorrência de dano ou reclamação de investidores clientes, uma falha da XP em recuperar a gravação original de ordens que representariam 0,00003% das ordens de clientes de varejo intermediadas no ano de 2015. Deste modo, a amostra selecionada pela SMI, originada de um processo de inspeção que teria outro objetivo e que empregaria uma metodologia concebida para outras finalidades, conteria um inequívoco viés de seleção, que nada permitiria inferir, a partir daquelas sete confirmações, sobre o real cumprimento das obrigações.

24. O equívoco da conclusão da SMI se deveria, em um primeiro nível, à impropriedade da amostra considerada na sua análise, que teria sido selecionada para outros fins. Nem a SMI nem a SFI buscariam, em sua inspeção original, apurar falhas nos sistemas e controles da XP Investimentos para fins de registro de ordens.

25. Em vez de selecionar negócios aleatoriamente dentre aqueles realizados por meio de todas as sociedades de agentes autônomos vinculados à XP, a área técnica teria selecionado duas sociedades específicas, com sede em uma mesma localidade (Rio de Janeiro).

26. Essa amostra quantitativamente limitada traria consigo alguns vícios porque consideraria um número pequeno de sociedades de agentes autônomos, de negócios e de clientes. O resultado da SMI seria, pois, pouco representativo daquilo que de fato corresponde à totalidade dos negócios intermediados já que as sete confirmações de ordem feitas *a posteriori* pelos clientes viriam de uma mesma e única sociedade de agentes autônomos.

27. Nenhuma consideração verdadeiramente estatística teria sido levada em conta neste processo ou nas análises conduzidas pela SMI, de modo que aqueles percentuais referidos pela área técnica não teriam qualquer valor ou utilidade de inferência estatística⁴.

⁴ Nesse sentido, a Defesa aponta para o entendimento do Institute of Internal Auditors (IIA), associação profissional internacional de autoridade interna, cuja atribuição é fornecer padrões e orientações de práticas da atividade de auditoria. O IIA afirma, em sua Orientação Prática nº 2320-3, que é “*essencial que a amostra de transações selecionada seja representativa de uma população*”. Sem essa garantia, a habilidade de tirar conclusões com base



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

28. Além disso, os negócios considerados não teriam sido escolhidos aleatoriamente, mas a partir de agentes autônomos que poderiam ter praticado irregularidades de outra natureza, evidenciando viés de seleção nos resultados da análise.

29. A Defesa ressalta as consideráveis diferenças entre o caminho tomado pela SMI e a metodologia empregada pela BSM – BM&FBOVESPA. Embora a BSM não divulgue sua metodologia para definição de amostras, ao analisar o cumprimento dos itens do PQO⁵ que tratam especificamente da obrigação de registro de ordens e manutenção de um sistema informatizado para arquivá-las, o autorregulador pediria evidências de um número bastante superior de ordens e consideraria muito mais sociedades de agentes autônomos.

30. Alega que a Guia da Bolsa teria sido auditada pela BSM em 2015 e 2016 e apresentado 100% dos registros das ordens solicitadas.

31. Afirma que uma auditoria ideal deve levar em conta parâmetros adequados para os fins que se destina. Neste particular, menciona que a XP teria implementado, em seu Regulamento de Auditoria de Agente Autônomo de Investimentos (“Regulamento de Auditoria AAI”)⁶, metodologia robusta para definição da amostra de ordens a serem analisadas. Tal Regulamento de Auditoria AAI determinaria, em seu item 5.1, que fossem analisadas as operações de todos os clientes atendidos por AAI, assim como os perfis operacionais dos clientes e dos AAI, a partir de uma série de critérios mais específicos, tais como (i) perfil do cliente; (ii) volume operado; (iii) corretagem; (iv) ferramenta de negociação utilizada; (v) prejuízo em operações; (vi) mercado operado; e (vii) giro de carteira.

32. Em 2015, mesmo ano da inspeção da SFI, a auditoria interna realizada pela XP teria auditado, por meio de suas auditorias mensais, um total de 9.057 evidências de ordens ao longo do ano inteiro. No mesmo ano, teriam sido realizadas, também, 666 auditorias de sociedades de agentes autônomos de investimento. E, no ano de 2016 e no primeiro semestre de 2017, o número de ordens auditadas internamente pela XP teria sido de 11.687 e 4.373, respectivamente, e o número de auditorias em sociedades de agentes autônomos de investimento teria sido de 1.140 e 744, respectivamente.

IV.A. NATUREZA DAS OBRIGAÇÕES

33. Segundo a Defesa, a obrigação de registrar as ordens (art. 12, parágrafo único, da Instrução CVM nº 505/2011) e a obrigação de manter um sistema para arquivar tais registros (art. 13 da mesma Instrução) serviriam para garantir que as ordens dadas pelo cliente fossem

na análise da amostra seria limitada, quando não errônea. Ademais, a amostragem não estatística poderia não ser realizada de forma objetiva e, deste modo, os resultados desta amostra poderiam não ser suportados matematicamente quando extrapolados para a população.

⁵ Programa de Qualificação Operacional da BM&FBovespa.

⁶ DOC 1 (pág. 43 – 58; doc SEI 0403752).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

adequadamente executadas pelos intermediários, na medida em que permitiriam confrontar as instruções enviadas às características do negócio executado.

34. Tais obrigações seriam de controle, isto é, obrigações instrumentais que visariam a prevenir e mitigar uma série dos riscos inevitavelmente associados ao exercício da atividade de intermediação. Deste modo, o registro das ordens e o seu arquivamento não seriam um fim em si mesmo e sim obrigações de controle da atuação do intermediário.

35. A SMI não estaria acusando a XP de não dispor de um sistema para registrar ordens ou de não dispor de um sistema para manter arquivados tais registros. O que a SMI teria constatado é que os registros originais de determinadas ordens não puderam ser devidamente recuperados e que a acusada teria apresentado confirmações legítimas, mas posteriores. Tratar-se-ia de uma questão não sobre a existência dos sistemas em si, mas sobre a sua efetividade.

36. Para a Defesa, não bastaria que se verificasse a ocorrência de uma falha pontual para que caracterizasse o descumprimento da obrigação correlata, mas seria preciso que aquelas falhas fossem recorrentes ou significativas a ponto de indicar que os controles estariam realmente aquém do que a regulação espera. A própria área técnica reconheceria essa lógica, ainda que implicitamente ao conduzir um exercício quantitativo⁷.

37. De acordo com a Instrução CVM nº 505/2011, não bastaria a ocorrência de uma ou algumas poucas falhas, e sim que elas fossem reiteradas, constantes e sistemáticas, ou seja, que refletissem um padrão recorrente de erro para que pudessem corroborar sua inadequação.

38. Além disso, as Instruções CVM nº 542 e 543, ambas de 20/12/2013 apontariam no mesmo sentido, afirmando que “a reiterada ocorrência de falhas” representaria evidência de implementação inadequada das regras ali contidas (art. 15, § 3º, inciso I e art. 27, § 3º, inciso I, respectivamente).

39. Se a SMI quisesse de fato avaliar o cumprimento das obrigações de registro de ordens e de manutenção de um sistema de arquivamento de tais registros, deveria ter realizado uma investigação apropriada, considerando questões específicas relacionadas à sua natureza.

40. Haveria uma série de decisões do Colegiado, relacionadas tanto a intermediários quanto a outros participantes do mercado, que teriam fornecido os parâmetros adequados para avaliar a conduta dos seus regulados em matéria de obrigações de controle.

41. Tais decisões seriam bastante firmes no sentido de que, para responsabilizar qualquer agente regulado por falhas em seus controles, a acusação deve provar que houve uma incidência

⁷ Um exemplo desse exercício quantitativo seria a referência, no Termo de Acusação e nos ofícios que o antecedem, ao percentual de ordens apresentadas como confirmações posteriores. Outro exemplo seria a própria seleção de uma amostra de ordens para, com base nela, apurar o cumprimento das obrigações discutidas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

reiterada de falhas, ou seja, que há uma efetiva deficiência nos controles internos daquela instituição extrapolando as inevitáveis falhas.

42. O Diretor Otavio Yazbek, no voto do PAS CVM nº 2010/9129, teria registrado que o descumprimento de obrigações mais específicas de controle depende da identificação de “falhas generalizadas” ou da inexistência dos procedimentos correspondentes no agente regulado, o que não poderia ser inferido da ocorrência de uma ou outra falha pontual.

43. O Colegiado, nos PAS CVM nº SP2005/0180 e nº SP2010/049, teria asseverado que um pequeno número de falhas no cumprimento da obrigação de cadastro seria insuficiente para concluir sobre infração às normas correspondentes.

44. Em voto vencedor no PAS CVM nº RJ2013/5456, o Diretor Pablo Renteria, discutindo a responsabilidade do administrador fiduciário de um fundo de investimento em direitos creditórios e do diretor daquela instituição pelo cumprimento de uma obrigação de fiscalização, teria consignado que não bastaria a ocorrência de falhas para caracterizar uma infração à norma e que, tendo em vista a natureza dessa obrigação, a acusação teria falhado em avaliar os controles instituídos pelos acusados e, portanto, em demonstrar que eles eram inapropriados para os fins a que se destinavam.

45. O Colegiado da CVM teria manifestado o mesmo entendimento em outro caso relacionado à responsabilidade de administrador fiduciário de fundos de investimento (PAS CVM nº RJ2006/4663).

46. No mesmo sentido, o então Diretor Otavio Yazbek, avaliando a responsabilidade de um administrador de companhia aberta pelo suposto descumprimento de seu dever de diligência, teria asseverado em seu voto que mesmo controles internos bem constituídos são passíveis de falhas, o que não necessariamente enseja a responsabilização dos administradores e que *“problemas pontuais [...], por melhor que seja o procedimento/ sistema, sempre podem ocorrer”* (PAS CVM nº 24/2006, j. em 18/02/2013).

IV.B. MANEJO INADEQUADO

47. Para além dessa limitação relacionada à natureza das obrigações, a Defesa ressalta que a via sancionatória deveria ser encarada como último recurso, como instrumento que, pelas suas próprias consequências, estaria à disposição do regulador (e da área técnica) apenas para aqueles casos que efetivamente justificarem uma medida mais contundente do aparato estatal.

48. Haveria uma série de outros mecanismos de que a área técnica poderia e deveria se valer nessas circunstâncias, antes de instaurar um processo, como envio de ofícios de alerta e realização de inspeções adequadas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

49. Somente uma inspeção adequada teria sido capaz de mensurar a efetividade dos controles da XP Investimentos e de chegar a alguma conclusão sobre o objeto do processo. Não sendo este o caso, as constatações da SMI poderiam, quando muito, motivar uma provocação da área técnica, na forma de um ofício de alerta, sobre a fiscalização que a XP Investimentos mantinha sobre a sociedade em particular e sobre os controles de que o intermediário dispunha para assegurar o cumprimento das obrigações.

50. A SMI teria feito exatamente isso em relação a outras falhas pontuais identificadas no curso da inspeção relacionadas à falta de atualização de dados cadastrais das sociedades visitadas e à presença, na sede de uma delas, de pessoas não vinculadas àquela sociedade de. Mesmo se deparando com indícios de descumprimento do dever objetivo e pontual de manter seus cadastros atualizados perante a CVM, a área técnica da autarquia não teria procedido à instauração de processo administrativo sancionador. Em lugar de fazer uso imediato do aparato punitivo do Estado, a SMI emitiu os Ofícios de Alerta nº 6, 8, 9 e 10/2017 /CVM/SMI/GME.

51. Porém, nenhum desses mecanismos teria sido adotado em relação à questão do registro das ordens, o que teria resultado em uma acusação incoerente e injusta.

52. A Defesa aponta que a pena deveria, pois, ser vista como o último recurso para enfrentar os conflitos que surgem das relações sociais. Haveria uma série de outros mecanismos capazes de enfrentar tais conflitos de forma mais adequada, como no caso daqueles de natureza compensatória e daqueles de natureza preventiva e orientadora (como os ofícios de alerta emitidos com fundamento na Deliberação CVM nº 542, de 09/07/2008).

53. Ademais, tivesse a área técnica se deparado com uma insuficiência de controles tão grave quanto faz crer, dificilmente teria a SMI (i) tardado um ano para provocar a XP Investimentos sobre o objeto deste processo; e (ii) se contentado em formular uma acusação em processo administrativo sancionador.

IV.C. CONFIRMAÇÕES EXTEMPORÂNEAS

54. A Defesa destacou que as confirmações extemporâneas de ordens pelos respectivos clientes, embora não fossem desejadas nem deveriam ser estimuladas como uma prática ou medida padrão, não seriam propriamente um problema, mas parte da solução possível, à luz das circunstâncias verificadas naqueles casos, para minimizar ao máximo os efeitos de determinadas dificuldades operacionais observadas no caso concreto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

55. A SMI já teria reconhecido, em outra ocasião⁸ que o principal objetivo do sistema de arquivamento (previsto no art. 13 da Instrução CVM nº 505/2011) seria assegurar que as operações fossem executadas conforme a vontade manifestada pelo cliente.

56. A própria SMI teria constatado, também, por meio das gravações entregues pela XP Investimentos, que não teria havido qualquer dano ou reclamação, e que os negócios executados refletiriam precisamente aquilo que fora solicitado pelos clientes em suas ordens. Essa inexistência de dano deveria ser levada em consideração por mais que a acusação tentasse se manter circunscrita ao campo do descumprimento formal da obrigação.

IV.D. CONDUTA DO DIRETOR RESPONSÁVEL

57. Segundo a Defesa, não se poderia confundir a extensão e a natureza da responsabilidade de pessoas naturais com aquelas que se atribui, originariamente, às pessoas jurídicas. Uma simples pessoa natural não poderia suportar os mesmos riscos da pessoa jurídica inclusive porque não goza de todos os seus benefícios. Portanto, a forma de apuração de responsabilidade do diretor responsável também deveria ser distinta.

58. A ocorrência de falhas e a materialização de eventos de risco seriam esperadas em negócios tão complexos como o do caso. Elas não conduziram, necessariamente, à punição dos regulados, como indicariam precedentes do Colegiado⁹.

IV.E. EMPENHO DOS ACUSADOS

59. Antes de tratar da estrutura de supervisão da XP Investimentos, a Defesa resolveu se referir às iniciativas dos acusados em matéria de registro e controle de ordens. Mais especificamente, os acusados teriam se empenhado no desenvolvimento de uma nova ferramenta para envio e registro de ordens de clientes, o *Trade Push*¹⁰, sendo o Diretor Responsável o maior catalisador de sua migração na XP Investimentos.

⁸ Nesse sentido, a Defesa faz referência à manifestação da SMI no Processo Administrativo SP2012/0139, decidido pelo Colegiado em 29/01/2013.

⁹ A Defesa cita, por exemplo, o voto da Diretora Relatora Luciana Pires Dias no PAS CVM nº RJ2012/12201, j. em 04/08/2015: “A melhor defesa para esses diretores é demonstrar que implementaram mecanismos adequados para assegurar o cumprimento do mandamento legal ou regulamentar, que supervisionaram com diligência, enfim, que promoveram esforços razoáveis para assegurar o cumprimento sistemático da regulação por aquela instituição e seus membros. Se esses mecanismos foram satisfatoriamente implementados e se o diretor em questão provou ser diligente, ainda que haja uma falha pontual, não há que se falar em responsabilidade desse diretor”. E, ainda, o voto do Diretor Relator Otavio Yazbek no PAS CVM nº 13/05, j. em 25/06/2012: “É importante destacar que a responsabilidade de tais diretores, nos normativos que a estabelecem, de modo geral não corresponde a uma obrigação de resultado. Nesse sentido, eventual responsabilização dos 'diretores responsáveis' deve passar pela não adoção de cuidados e esforços voltados ao cumprimento das regras dirigidas às instituições de que eles são 'responsáveis'”.

¹⁰ Doc 02 (pág. 59 – 66; doc. SEI 0403752).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

60. A conduta de Guilherme Benchimol teria sido sempre bastante enfática no sentido de afirmar que este seria um passo obrigatório para a XP Investimentos. Um dos maiores êxitos da ferramenta estaria ligado à sua agilidade e confiabilidade em matéria de registro de ordens.

61. O *Trade Push* facilitaria a comunicação entre o AAI e o cliente, além de impedir a gestão irregular de recursos do investidor, na medida em que a operação só seria executada mediante aprovação do cliente, em um processo, do começo ao fim, registrado pelo sistema.

62. A migração do registro de ordens da XP Investimentos para o sistema *Trade Push* viria apresentando resultados significativos de conformidade com a regulação e já teria sido concluída em aproximadamente 70% das sociedades de agentes autônomos atualmente vinculadas à XP.

63. A Defesa lembrou que o tamanho da base de clientes da XP Investimentos (cerca de 350.000 clientes ativos) e a quantidade de agentes autônomos de investimento com quem a mantém relação (cerca de 2.415) requereriam que a criação e a implementação de uma ferramenta tão abrangente como esta fossem feitas de forma bastante cuidadosa.

IV.F. ESTRUTURA DE SUPERVISÃO DA XP

64. Além do desenvolvimento do *Trade Push*, a XP Investimentos viria realizando uma série de auditorias internas relacionadas à conduta dos agentes autônomos vinculados, o que contribuiria para que tais agentes atuassem de acordo com a regulação da CVM e com as obrigações de registro de ordens atribuídas aos intermediários.

65. Em termos de criação de uma estrutura funcional, em 2015, a XP Investimentos teria criado a XP Supervisão de AAI ("XPSA"), uma estrutura independente dotada de autonomia financeira e orçamentária, responsável por fiscalizar as atividades dos agentes autônomos e composta por dois núcleos: o Conselho de Supervisão de AAI e a Auditoria de AAI¹¹.

66. O Conselho de Supervisão de AAI se reuniria mensalmente e seria formado por uma equipe multidisciplinar dos principais executivos da XP Investimentos, incluindo o Diretor Responsável. Caberia ao Conselho de Supervisão de AAI aplicar penalidades¹² e julgar as irregularidades consideradas "gravíssimas" que tenham sido cometidas pelos agentes autônomos de investimento, podendo o Conselho de Supervisão, inclusive, avaliar quaisquer irregularidades não descritas expressamente no Regulamento de Auditoria de AAI.

¹¹ As atribuições da XPSA (item 4.1. do Regulamento), incluem: (i) fiscalizar e supervisionar os agentes autônomos contratados pela XP Investimentos; (ii) realizar trabalhos educativos por meio de treinamentos, cursos e comunicados; (iii) identificar violações ao Regulamento de Auditoria de AAI, à legislação e à regulamentação vigente; (iv) punir os agentes autônomos que cometam irregularidades; e (v) fornecer à XP Investimentos dados quantitativos e qualitativos que permitam analisar a qualidade do serviço prestado pelos agentes autônomos.

¹² O Regulamento prevê, em seu item 4.2, a aplicação das seguintes medidas disciplinares aos AAI: (i) multa pecuniária e adesão a termo de compromisso; (ii) suspensão do direito de intermediação pela XP Investimentos por até 90 dias; e (iii) distrato do contrato de prestação de serviço de AAI.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

67. A Auditoria de AAI, por sua vez, funcionaria como um corpo técnico de supervisão da atuação dos agentes autônomos de investimento, a quem caberia: (i) desenvolver um plano anual de auditoria, utilizando metodologia baseada em riscos apropriada; (ii) submeter o plano anual de auditoria ao Comitê de Auditoria da Defendente para revisão e aprovação; (iii) estabelecer um programa de educação continuada dos agentes autônomos de investimento; (iv) emitir reportes ao Conselho de Supervisão dos AAI; e (v) investigar atividades suspeitas.

68. Quando solicitado pela Auditoria de AAI, os agentes deveriam enviar as evidências das ordens de seus clientes. Essa auditoria de periodicidade mensal teria como referência as operações executadas nos seis meses anteriores ao início da auditoria.

69. Dentre outros aspectos, a Auditoria de AAI avaliaria se tais ordens: (i) foram dadas pelo cliente ou por seu representante legal cadastrado; (ii) se foram dadas previamente à execução da operação, isto é, se não são confirmações posteriores; (iii) se apresentam os dados completos da operação (código/nome do cliente, papel/ ativo, quantidade, valor do ativo e natureza da operação); e (iv) foram registradas em canal autorizado e gravado pela acusada.

70. Caso se verificasse irregularidades, o Regulamento de Auditoria de AAI preveria uma matriz de penalidades aplicáveis, de modo que a estrutura de supervisão ficaria dedicada não apenas a fiscalizar a atuação dos agentes autônomos, mas capaz, também, de impor-lhes determinadas sanções em caso de descumprimento das normas aplicáveis.

71. No que se refere a irregularidades relacionadas ao objeto deste processo, a Defesa argumenta que tal matriz preveria uma multa de R\$2.000,00 e um *fee* de 150% do valor da corretagem por ordem não apresentada. No caso de confirmações posteriores de ordem, aplicar-se-ia uma multa de R\$1.000,00 e *fee* de 50% do valor da corretagem por ordem. Ambas as penalidades seguiriam a relação da tabela abaixo, para o número de infrações verificadas:

Infração	Ausência de Ordem	Confirmação Posterior
1º apontamento	R\$2.000,00	R\$1.000,00
2º apontamento	R\$2.500,00	R\$1.500,00
3º apontamento	R\$3.000,00	R\$2.000,00
4º apontamento	R\$3.500,00	R\$2.500,00
5º apontamento	R\$4.000,00	R\$3.000,00

IV.G. CONCLUSÕES

72. Concluindo, a Defesa afirmou que a acusação teria buscado fundamentar um processo administrativo sancionador em sete confirmações posteriores de ordem, sem qualquer dano a clientes, todas originárias de uma mesma e única sociedade de agentes autônomos de investimento, dentro de um universo de 20.439.909 de negócios de clientes de varejo intermediados pela XP no ano de 2015, o que seria incabível para uma imputação desta natureza.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

73. Além disso, a amostra selecionada pela SMI teria origem em um processo de inspeção com outro objetivo, que não o de verificar o cumprimento do art. 12, parágrafo único e do art. 13, *caput* e parágrafo único, da Instrução CVM nº 505/2011.

74. A SMI não questionaria a existência desses sistemas na acusada, mas a sua efetividade. Dada a natureza dessas obrigações, contudo, seria preciso ter em mente que nem toda falha implica uma infração ou denota a fragilidade dos correspondentes controles.

75. Inclusive, inúmeros precedentes do Colegiado corroborariam essa conclusão apontando que, para que se verifique um efetivo descumprimento de obrigações de controle, a acusação deve provar que houve falhas recorrentes.

76. As confirmações extemporâneas de ordens pelos clientes, embora não sejam ideais nem encorajadas pelos Defendentes, serviriam para comprovar que as ordens foram executadas conforme a vontade dos clientes.

77. Ademais, não se poderia confundir a responsabilidade de um diretor responsável e a da pessoa jurídica com qual ele mantém vínculo. Sob a direção e supervisão de Guilherme Benchimol, a XP Investimentos teria realizado, inclusive, uma série de aprimoramentos em seus processos e obrigações de controle.

78. Por fim, a XP Investimentos contaria com uma estrutura robusta e independente de supervisão de atividades de seus agentes autônomos, através da XPSA, da Auditoria de AAI e do Conselho de Supervisão de AAI.

V – DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

79. Em 20.02.2018, o presente processo foi distribuído para minha relatoria (Doc Sei nº 0441676).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR-RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.002587/2017-77
Reg. Col. nº 0968/18

Acusados: XP Investimentos CCTVM S.A.
Guilherme Dias Fernandes Benchimol

Assunto: Apurar responsabilidade por falhas no registro e arquivamento de ordens. Infração ao artigo 12, parágrafo único, e ao artigo 13, *caput* e parágrafo único, da Instrução CVM nº 505/2011.

Diretor Relator: Henrique Machado

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Cuida-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação” ou “área técnica”) para apurar as responsabilidades da XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP” ou “Corretora”) e de seu diretor responsável, Guilherme Dias Fernandes Benchimol (“Guilherme Benchimol”), por supostas falhas no registro e arquivamento de ordens transmitidas por clientes, em infração ao artigo 12, parágrafo único, e ao artigo 13, *caput* e parágrafo único, da Instrução CVM nº 505, de 27 de setembro 2011¹.

2. A Acusação tem por fundamento o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/Nº 006/2016, o qual relata os trabalhos de fiscalização realizados em sociedades de agentes autônomos e na própria XP pela Superintendência de Fiscalização Externa (“Inspeção”) desta CVM (Doc. Sei nº 0262439). Segundo a Inspeção, teria sido possível constatar que sete de 46 operações selecionadas não teriam as correspondentes ordens prévias transmitidas pelos clientes,

¹ Art. 12. O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: I – escrito; II – telefone e outros sistemas de transmissão de voz; ou III – sistemas eletrônicos de conexões automatizadas. Parágrafo único. Todas as ordens devem ser registradas, identificando-se o horário do seu recebimento, o cliente que as tenha emitido e as condições para a sua execução.

Art. 13. O intermediário deve arquivar os registros das ordens transmitidas pelos clientes e as condições em que foram executadas, independentemente de sua forma de transmissão. Parágrafo único. O sistema de arquivamento de que trata o *caput* deve ser protegido contra adulterações e permitir a realização de auditorias e inspeções.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ou seja, 15,22% da amostra apresentou falha quanto ao registro das ordens. Com base nessa evidência, a Acusação sustenta a violação aos artigos 12 e 13 da ICVM nº 505/2011.

II. MÉRITO

3. Os acusados não negam a existência da falha apontada pela Acusação, contudo, alegam que ela resultaria de erro operacional isolado relacionado à dificuldade de localizar os registros correspondentes em tempo hábil. Acrescentam que nenhuma das ordens teria sido executada em desacordo com as instruções dos respectivos clientes, conforme atestariam as confirmações de ordens extemporâneas assinadas pelos clientes da Corretora.

4. Alegam também que a Acusação teria se baseado em uma amostra pouco representativa – 0,00003% das ordens de clientes de varejo intermediadas pela XP em 2015 –, originada de um processo de que teria outro objetivo com metodologia concebida para outras finalidades, a revelar evidente equívoco de seleção.

5. Essa amostra quantitativamente limitada traria, segundo a defesa, alguns vícios porque consideraria um número pequeno de sociedades de agentes autônomos, de negócios e de clientes. Assim, o resultado utilizado pela Acusação seria pouco representativo daquilo que de fato corresponde à totalidade dos negócios intermediados já que as sete confirmações de ordem feitas posteriormente pelos clientes viriam de uma mesma e única sociedade de agentes autônomos.

6. Alegam ainda que, de acordo com a Instrução CVM nº 505/2011, não bastaria a ocorrência de algumas poucas falhas, mas que elas fossem reiteradas, constantes e sistemáticas, de modo a refletir um padrão recorrente de erro para que pudessem corroborar sua inadequação. Nessa direção, a defesa cita as Instruções CVM nº 542 e 543, de 20 de dezembro de 2013, que apontariam que “*a reiterada ocorrência de falhas*” representaria evidência de implementação inadequada das regras ali contidas (art. 15, § 3º, inciso I, e art. 27, § 3º, inciso I, respectivamente).

7. Em relação à materialidade do ilícito, tenho que os argumentos de defesa não são capazes de afastar a ocorrência da irregularidade.

8. O relatório da Inspeção demonstra que a SMI e a SFI não fizeram uso da amostragem estatística ou probabilística, como quer fazer parecer a defesa. A amostra selecionada pela Inspeção é denominada não estatística ou não probabilística por ter utilizado em sua definição



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

critérios subjetivos, baseados nas experiências profissionais de cada uma das áreas técnicas, justamente para buscar “estimadores tendenciosos”².

9. Dito de outra forma, o objetivo da Inspeção não era ter uma amostra representativa da população de todas as ordens emitidas pela XP, mas selecionar uma amostra com viés exatamente para obter maiores chances de detectar desvios de conduta praticados por agentes autônomos de investimentos em relação às normas emitidas pela Autarquia, conforme resta evidente do planejamento da Inspeção³ a seguir transcrito:

O período contemplado nos testes a serem realizados e nas evidências documentais a serem requisitadas será os 3 (três) meses anteriores ao início da inspeção, ou seja, abril, maio e junho de 2015.

A GME indicará mais dois Agentes Autônomos de Investimento – AAI (Pessoa Jurídica, preferencialmente de médio ou grande porte) a serem incluídos na amostra de agentes a serem inspecionados para atendimento à Solicitação de Inspeção, **a qual já contém a Guia da Bolsa Agentes Autônomos de Investimentos Ltda**, totalizando, assim, um total de três AAIs.

Deverão ser selecionados quatro clientes de cada um dos três agentes AAIs, considerando **clientes pessoa física, dentre aqueles com maior volume financeiro e com maior número de operações no período, preferencialmente dentre aqueles que transmitam ordens pelos canais de voz e/ou escrita (incluindo mensageria eletrônica).**

Deverão ser selecionadas para exame 4 (quatro) ordens de cada cliente, considerando apenas aquelas transmitidas pelos canais de voz e/ou escrita (incluindo mensageria eletrônica), perfazendo, portanto, um total de 48 ordens.

10. Como se vê, a SMI e a SFI selecionaram, com base na experiência em fiscalizar e advertir os desvios de condutas praticados pelos intermediários e seus correspondentes agentes autônomos, uma amostra tendenciosa, constituída por clientes de varejo com o maior número de operações efetuadas exclusivamente pelos canais de voz e escrita e por intermédio de agentes autônomos de investimentos.

11. Além desses parâmetros, a amostra deveria conter obrigatoriamente a Guia de Bolsa Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. (“Guia de Bolsa”), a revelar que a escolha desta sociedade também não teve nada de aleatório. Isso porque o presente processo teve origem em denúncia realizada pelo investidor M.M.M.N. em desfavor da Guia de Bolsa por supostamente prestar serviços de consultoria e de administração irregular de recursos, conforme consta do Processo CVM nº RJ 2014/10099.

² “Uma amostra probabilística caracteriza-se por ser extraída da população de tal forma que cada item [ou pessoa] tem as mesmas chances de ser selecionado que os demais”. ZENTGRAF, Roberto. *Estatística Objetiva*. 5ª ed. – Rio de Janeiro: ZTG Editora, 2009, p. 297-298.

³ DA CUNHA, Paulo R., BEUREN, Ilse M. *Técnicas de Amostragem Utilizadas nas Empresas de Auditoria Independente Estabelecidas em Santa Catarina. R. de Contabilidade e Finanças*, São Paulo, v.1, nº 40, p. 69-70, Jan/Abr 2006.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

12. Diante disso, o uso da amostragem não probabilística no presente processo mostrou-se adequado, pois a Inspeção precisava trazer, de forma objetiva e prática, no menor espaço de tempo, evidências para convergir com as necessidades de informações solicitadas pela SMI.

13. Por tal razão, tenho que os argumentos da defesa no sentido de desqualificar a amostra utilizada no presente processo não se prestam para afastar as evidências coletadas pela Inspeção, nem as conclusões delas obtidas. E, mais do que isso, o art. 12 da ICVM 505/11 é bastante direto ao definir objetivamente a necessidade de o intermediário registrar todas as ordens transmitidas pelos clientes, *in verbis*:

Art. 12. O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: I – escrito; II – telefone e outros sistemas de transmissão de voz; ou III – sistemas eletrônicos de conexões automatizadas. Parágrafo único. **Todas as ordens devem ser registradas, identificando-se o horário do seu recebimento, o cliente que as tenha emitido e as condições para a sua execução.**

14. Não se trata de excesso da regulação exigir o registro de todas as ordens, pois é pressuposto do bom funcionamento do mercado de bolsa que toda operação executada seja precedida de ordem prévia por meio da qual o cliente manifesta ao intermediário sua vontade inequívoca de negociar determinado ativo em seu nome nas condições que especificar. O tipo administrativo não carrega consigo nenhuma exceção, vez que se trata de regra de transparência e confiabilidade do mercado de capitais.

15. E, como visto, a Inspeção constatou sete situações específicas de operações executadas pela XP por intermédio da Guia de Bolsa sem registro de ordem prévia dos clientes, a revelar que a Corretora não cumpriu a obrigação fixada objetivamente na norma de regência, configurando, portanto, o ilícito administrativo.

16. Por isso, apesar das bem elaboradas razões da defesa, não merece acolhida a tese de que não bastaria a ocorrência de poucas falhas para que restasse evidenciada a irregularidade em face do art. 12 da ICVM nº 505/2011, pois a norma em comento não permite tal inferência, pelo contrário, é taxativa ao determinar o registro de todas as ordens.

17. Nesta direção, cabe salientar que, independentemente do tamanho da “amostra”, o descumprimento de outras regras de controle formal também fixadas objetivamente pela regulação do mercado de capitais tem sido objeto de reprimenda pelo Colegiado da CVM. No julgamento do PAS CVM nº RJ2012/1606, de 04.02.2014, por exemplo, o Colegiado responsabilizou a instituição intermediária e o seu diretor responsável em razão da falta de atualização do cadastro de um único investidor, conforme trechos do voto condutor da Diretora Ana Novaes⁴ a seguir reproduzido:

⁴ Acessado em 30.11.2018 e disponível para consulta no site da CVM no endereço eletrônico http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2014/20140204_PAS_RJ20121606.pdf.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Entretanto, a Instrução CVM n.º 301/99 foi alterada, em 08/01/2008, pela Instrução CVM nº463/08. A inclusão do § 3º ao art. 3º trouxe, pela primeira vez, o tratamento objetivo do prazo para a atualização cadastral ao estabelecer que os dados cadastrais dos clientes ativos deveriam ser atualizados em “períodos não superiores a 24 meses”. Além disso, a Instrução CVM nº 463/08 conferiu, em suas disposições transitórias, o prazo de 90 dias para que as instituições a ela sujeitas se adequassem.

Ou seja, pela nova regra, não havia mais dúvida alguma de que a ficha cadastral de A.D. deveria ter sido atualizada em abril de 2008, entretanto, isso só ocorreu cinco meses depois, em setembro de 2008. Cabe ressaltar que, nesse período, o cliente continuou a operar normalmente.

Assim, considero que a SLW excedeu o prazo para atualizar a ficha cadastral do cliente A.D. e voto pela condenação da corretora e de seu diretor.

18. De toda forma, ainda que eu considere necessário um juízo de ponderação e proporcionalidade na responsabilização dos participantes em casos que tais, tenho que ele é atendido, no presente caso, pelo percentual de inconformidade dentro da amostra da Inspeção. É nesse sentido a decisão do Colegiado, no julgamento do PAS CVM nº SP 2013/456, de 20.03.2018, de minha relatoria. Naquela oportunidade, esta CVM responsabilizou a instituição intermediária e seu diretor responsável por falhas na atualização de 18 dos 25 cadastros selecionados na amostra da inspeção que fundamentou a Acusação, afastando a alegação da defesa de que a amostra de cadastros utilizada pela Acusação teria sido pouco representativa do total dos clientes da corretora. O parâmetro adotado no presente caso, portanto, está em linha com entendimento recente deste Colegiado.

19. Ainda sobre a materialidade, cabe mencionar que a BSM Supervisão de Mercados (“BSM” ou “Autorregulador”), por meio de seu Comunicado Externo 020/2017-DP⁵, de 21.12.2017, informou que o percentual de tolerância máxima para ausência de ordem para os planos de trabalho de 2018 nas auditorias operacionais dos intermediários seria de 7%, de modo que ***“qualquer extrapolação do percentual de ausência de ordem em relação à tolerância máxima (7% para 2018) sujeitará o Participante à medida sancionadora”***.

20. Também de acordo com o referido comunicado, **a tolerância máxima de ausência de ordem não se aplicaria às situações de ausência de ordem identificadas em (i) reclamações ao mecanismo e ressarcimento de prejuízos (“MRP”), (ii) investigações de denúncias e (iii) investigações de supervisão de operações e ofertas.**

21. Observa-se, assim, que a irregularidade apontada pela Inspeção está em linha com a atuação da BSM, pois a amostra utilizada pela Inspeção apresentou mais que o dobro (15,22%) do percentual de ausência de registro de ordem tolerado pelo autorregulador (7%). Nada obstante, cabe repisar que o presente processo teve origem em denúncia realizada por investidor

⁵ Disponível no endereço < <http://www.bsm-autorregulacao.com.br/assets/file/leis-normas-regras/CE-0202017-DP.pdf> >, acessado em 30.10.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

à CVM, com posterior acionamento do MRP, revelando circunstância em que, independentemente do percentual de ausência de ordem, o intermediário sofreria medida sancionadora pela BSM.

22. Não é por outra razão que a BSM informou por meio do já mencionado comunicado que “a ausência de ordem abaixo da tolerância máxima não implica ausência de apontamentos de auditoria”, de forma que “**todas não conformidades relativas à ausência de ordem constarão do relatório de auditoria operacional enviado ao Participante, que, em resposta ao relatório de auditoria, deverá apresentar plano de ação à BSM para regularização da não conformidade**”.

23. Embora tais razões sejam suficientes para afastar a afirmação da defesa de que a redação do art. 12 representaria uma obrigação de controle sobre as atividades do intermediário e, como tal, estaria **inevitavelmente** sujeito a falhas, é oportuno registrar que vários intermediários apresentam zero por cento de ausência de registro de ordem em suas operações de bolsa, a demonstrar que, diferentemente do alegado, falhas referentes ao registro de ordem não são esperadas, tampouco admitidas.

24. Neste sentido, cabe reproduzir a tabela de conformidade dos intermediários em relação à obrigação de somente executar operações mediante ordem prévia, elaborada pela BSM com os dados obtidos em suas auditorias operacionais⁶:

Ano	Percentual de ausência de ordem – Auditoria operacional					
	Participantes auditados	Média de ausência de ordem	Máxima ausência de ordem	Participantes com ausência de ordem acima da média	Participantes com ausência de ordem abaixo da média (diferente de zero)	Participantes sem ausência de ordem (zero)
2012	76	13,1%	66,67%	30 (39,5%)	16 (21,0%)	30 (39,5%)
2013	73	16,9%	88,72%	27 (37,0%)	14 (19,2%)	32 (43,8%)
2014	70	9,4%	85,33%	20 (28,6%)	16 (22,8%)	34 (48,6%)
2015	74	7,7%	48,40%	18 (24,3%)	13 (17,6%)	43 (58,1%)
2016	71	4,1%	50,00%	22 (31,0%)	5 (7,0%)	44 (62,0%)

25. É fácil perceber da tabela acima que, no mesmo ano da Inspeção (2015), mais da metade dos intermediários (58,1%) não apresentaram falha no registro de ordens, a revelar não se tratar de obrigação impossível de ser cumprida, mas, sim, exequível por número considerável de instituições intermediárias. Mais do que isso, a tabela demonstra que o registro e o arquivamento da ordem prévia emitida pelo cliente não deve, necessariamente, conter falhas.

26. Nesse contexto, imperioso comentar o importante trabalho desempenhado pela BSM no seu exercício de autorregulação do mercado, aferível a cada ano pelo aumento do número de intermediários que cumprem rigorosamente com a determinação contida no art. 12 da ICVM nº 505/11, qual seja, garantir a execução mediante prévia ordem para todos os negócios intermediados, seja na matriz, em filiais ou em prepostos.

⁶ Disponível no endereço < <http://www.bsm-autorregulacao.com.br/assets/file/leis-normas-regras/CE-0202017-DP.pdf> >, acessado em 30.10.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

27. No presente julgamento, além de abonar a conduta do autorregulador neste assunto em particular, convém destacar a importância das estatísticas produzidas pelos seus trabalhos de auditoria. Nesse sentido, ao referenciar os dados constantes da tabela acima, não proponho a avocação de regras abstratas discricionariamente adotadas pelo autorregulador. O percentual de ausência de registro de ordem fixado pelo autorregulador (7%) como critério para a abertura de processo sancionador é derivado do grau de aderência dos participantes de mercado nos exercícios anteriores e, portanto, tem substrato em evidências empíricas. Ademais, os dados fornecem a devida transparência e objetividade na atuação sancionadora, além de conferirem incentivo adicional para o contínuo aperfeiçoamento dos participantes.

28. A defesa também alega que a SMI dispunha de outro instrumento regulatório a sua disposição de que poderia se valer nessas circunstâncias, antes de instaurar um processo sancionador, a saber: a expedição de ofícios de alerta.

29. Nesse ponto, embora reconheça que as características apresentadas no presente processo poderiam recomendar a emissão de ofício de alerta, isto é, a atuação orientadora da CVM no sentido de apontar as falhas identificadas no registro de ordens transmitidas por intermédio da Guia de Bolsa, com o intuito de permitir a adequação do regulado às normas legais e regulamentares, tenho que o histórico dos Acusados neste processo possa ter influenciado a decisão da SMI em escolher o caminho mais gravoso. Como já dito, o processo teve origem em reclamação apresentada pelo investidor M.M.M.N. contra a Guia de Bolsa por supostamente ter executado operações sem a sua autorização, no período compreendido entre 10.09.2010 e 02.05.2011. Segundo alegou, os agentes autônomos vinculados à XP teriam executado operações em seu nome conforme melhor lhes aprouvessem e depois as informavam por email ao reclamante, o que evidenciaria, no seu entender, a gestão indevida de seus recursos.

30. Essa reclamação também foi objeto de recurso interposto pelo reclamante ao Colegiado da CVM contra a decisão da BSM, que, embora tenha reconhecido a falha da XP no tocante ao registro das ordens relativas a operações executadas pela Guia de Bolsa em nome do reclamante, indeferiu o pedido porquanto o reclamante não teria impugnado tais operações logo após ter tido ciência delas, o que, no sentir da BSM, equivaleria à ratificação tácita das operações.

31. Ao apreciar as razões recursais no âmbito do Processo Administrativo CVM nº RJ2013/0267 em 18.03.2014, o Colegiado deu provimento ao recurso por entender que a XP teria se utilizado da Guia de Bolsa para prestar serviço de consultoria para o reclamante sem que esta sociedade estivesse autorizada pela CVM a prestar tal serviço, conforme obrigação contratual estabelecida pela XP com o reclamante. Tal delegação indevida teria nexo causal



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

direto com os prejuízos sofridos pela reclamante, a autorizar, nos termos do voto da Diretora Relatora Ana Novaes⁷, o ressarcimento por meio do MRP.

32. Neste passo, convém transcrever excerto do voto da Diretora Relatora Ana Novaes⁸ em que ela acompanha o entendimento do Conselheiro Relator da BSM quanto à necessidade da gravação de **todas** as operações transmitidas por meio de voz pelo intermediário, uma vez que a XP não havia apresentado o registro prévio de determinadas operações executadas pela Guia de Bolsa em nome do reclamante:

⁷Nas palavras da Diretora Ana Novaes: “A meu ver, é patente que a delegação do serviço de consultoria à pessoa que não está autorizada a fazê-lo implica em quebra desse dever de diligência e, portanto, pode implicar na responsabilidade da Corretora. Assim, entendo que ao contrário do que acontece normalmente, a irregularidade ora verificada tem nexos causal direto com o prejuízo sofrido pelo Reclamante, pois a decisão de investimento do investidor fica comprometida pelo assessoramento inadequado permitido pela Reclamada. 18. É oportuno lembrar que a Instrução CVM Nº 43/85 determina que os consultores de valores mobiliários devem ser pessoas com comprovada experiência. Isso serve como garantia ao mercado de que ao contratar tal serviço o investidor estará sendo assessorado por pessoa com capacidade técnica. 19. Não só os agentes da Guia da Bolsa não estavam devidamente autorizados a realizar tal atividade, como ao fazê-lo eles estariam atuando em conflito de interesse, já que a remuneração dos mesmos deriva da corretagem gerada com as operações do investidor. 20. Assim sendo, ao que me parece, a Corretora ofertou ao Reclamante um serviço de consultoria, mas falhou em sua obrigação de provê-lo adequadamente, permitindo que o Reclamante operasse sob a orientação de pessoa que não era apta a fazê-lo. Tal fato é um claro indicativo de quebra na relação de confiança que deve existir entre o investidor e o intermediário e isso é de especial importância quando se considera que a Reclamada participou do processo de educação do investidor. Nesse sentido, vale citar que o Reclamante realizou junto à Corretora o curso “Como investir na bolsa de valores com ênfase em análise técnica”, de 10 horas de duração. Segundo ele, no curso os instrutores destacavam a capacidade técnica dos quadros da Corretora, inclusive incitando os alunos a 3/4 assinarem contrato com a Corretora, sob a promessa de ganhos fáceis e seguros. 21. Portanto, entendo que o prejuízo por tal irregularidade se encontra no âmbito do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos, que tem como cláusula geral o ressarcimento de prejuízos decorrentes de ‘ação ou omissão de pessoa autorizada a operar, ou de seus administradores, empregados ou prepostos, em relação à intermediação de negociações realizadas na bolsa ou aos serviços de custódia’”. Disponível em http://www.cvm.gov.br/decisoes/2014/20140318_R1/20140318_D09.html, acessado em 30.10.2018.

⁸ Cabe mencionar que o provimento do recurso foi revisto de ofício pelo Colegiado em 11.02.2016, tendo em vista a decisão ter sido fundamentada em fato não controvertido nos autos. No pedido de revisão, a XP Investimentos arguiu, em síntese, que a decisão do Colegiado de 18.03.2014 baseou-se em fato não alegado anteriormente no processo administrativo e sobre o qual não teve sequer a oportunidade de se defender, qual seja, a suposta delegação do serviço de consultoria de valores mobiliários a preposto não autorizado a fazê-lo, em violação ao art. 16, IV, alínea “a”, da Instrução CVM 434/2006. De acordo com a XP Investimentos, a decisão objeto de recurso teria modificado a causa de pedir da reclamação, justificando o cabimento do ressarcimento em fato distinto e jamais suscitado pelo Reclamante. Em seu voto, o Relator Pablo Renteria destacou, inicialmente, que a regulamentação vigente não admite a legitimidade de intermediário reclamado para recorrer ou interpor pedido de reconsideração ao Colegiado em sede de MRP. Não obstante, o Relator salientou que, à luz do art. 63, § 2º, da Lei nº 9.784/1999 e do inciso IX da Deliberação CVM 463/2003, cumpre ao Colegiado rever de ofício a sua decisão quando houver erro a ser corrigido. Nesse sentido, o Relator constatou que a decisão de 18.03.2014 baseou-se em fato não alegado pelo Reclamante em sua reclamação e tampouco controvertido pelas partes interessadas e apreciado pelas diversas instâncias decisórias. No entendimento do Relator, tal procedimento não se coaduna com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, caracterizando, assim, o *error in procedendo*. Em sua visão, seria necessário o reexame da matéria, com a consequente revisão da decisão do Colegiado de 18.03.2014, considerando exclusivamente o fundamento da reclamação formulada pelo Reclamante. Disponível em http://www.cvm.gov.br/decisoes/2016/20160211_R1/20160211_D8723.html, acessado em 30.10.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Por fim, vale citar o seguinte trecho do voto do Conselheiro-Relator no julgamento do Pleno da BSM, Sr. Cláudio Ness Mauch (fl. 795):

"Sem outra opção e entendendo que a gravação de todas as operações é uma providência da mais alta importância para a necessária transparência e confiabilidade do mercado, e que **sempre recairá sobre os intermediários a observância mais forte da regulamentação vigente**, entendo, que ainda que sem uma convicção robusta da procedência do pedido do Reclamante, deve ser a ele (Reclamante) ressarcido, conforme parecer da GJUR". (ênfase adicionada).

O que merece destaque de tal parágrafo é a assertiva, que entendo correta, de que a observância da regulamentação vigente recai primeiro e com mais força sobre os intermediários do que sobre os demais agentes de mercado. **O problema é ainda composto pela falta das gravações que já eram exigíveis à época, especialmente quando se trata de uma Corretora [XP] detentora do selo PQO.**

33. Neste contexto, qual seja, em que a XP não conseguiu garantir a integridade das ordens transmitidas pelos clientes por meio da Guia de Bolsa desde, ao menos, 2010, não se pode retirar a razão da área técnica em propor o presente processo sancionador porquanto se tratava, na realidade, de falha reiterada da XP envolvendo aquela sociedade de agentes autônomos, na qual a totalidade das operações sem registro foi constatada pela Inspeção, conforme se verifica do trecho do relatório da Inspeção a seguir transcrito:

Apuramos, também, que sete dos 46 registros encaminhados (representando 15,22%) foram efetuados em data posterior a da operação, tendo o teor do diálogo entre o AAI e o cliente permitido identificar que aquele estava precisando confirmar a ordem deste, realizada em data passada, para cumprimento de exigência de auditoria da CVM. Tais registros são pertinentes às ordens destacadas no Quadro 10, todas do AAI Guia da Bolsa:

Quadro 10 – Operações com registro da ordem em data posterior a da operação

DT_NEGOCIO	CD_NEGOCIO	NR_NEGOCIO	CD_NA TOPE	CD_CLIENTE	QT_QT DESP	VL_NEGOCIO	VL_VOLUM E	ESCRITÓRIO DO AAI	HH_N EGO CIO
06/04/2015	BBAS3	16300	C	46731	1.500	25,15	37.725,00	Guia da Bolsa	10:43
20/05/2015	PETR4	61090	C	46731	2.000	13,10	26.200,00	Guia da Bolsa	10:34
28/04/2015	CSNA3	147660	V	51241	4.200	7,86	33.012,00	Guia da Bolsa	17:41
21/05/2015	BBAS3	42450	C	51241	1.600	24,45	39.120,00	Guia da Bolsa	11:55
05/06/2015	PARC3	2990	V	96645	300	13,60	4.080,00	Guia da Bolsa	10:18
15/06/2015	ECOO11	10	V	96645	500	60,64	30.320,00	Guia da Bolsa	12:01
01/04/2015	PETR4	466730	V	223618	4.100	10,20	41.820,00	Guia da Bolsa	16:31

34. E, muito embora a defesa tenha alegado que essas falhas estariam relacionadas à dificuldade de localizar os registros correspondentes em tempo hábil, em nenhum momento ela trouxe aos autos evidências de que as operações referenciadas na tabela foram executadas mediante ordem prévia dos clientes, mesmo depois de mais de três anos de sua ocorrência.

35. Por oportuno, impende ainda analisar a alegação da defesa de *que as confirmações extemporâneas de ordens pelos respectivos clientes, embora não sejam desejadas nem devam ser*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

estimuladas como uma prática ou medida padrão, não são propriamente um problema, mas parte da solução possível. É evidente que a confirmação posterior das ordens pelos clientes não é o problema. O problema é a própria ausência prévia das ordens que subjaz a confirmação posterior. Não à toa os acusados estão sendo responsabilizados pela ausência das ordens e, não, por tê-las confirmado posteriormente.

36. O aspecto principal da confirmação posterior das ordens, para fins deste processo administrativo sancionador, é que esse ato não elide a irregularidade administrativa consistente em realizar operação sem prévia ordem do cliente e de não arquivar os respectivos registros e as condições em que foram executadas. De outro modo, diferir-se-ia aos investidores o cumprimento da regra de conduta dirigida aos intermediários e enfraquecer-se-ia o incentivo imposto às corretoras para o cumprimento dessa importante regra de *compliance*.

37. Aliás, a própria defesa relata que as irregularidades relacionadas ao objeto deste processo também são punidas pela XP Supervisão de AAI quando identificadas nos trabalhos de auditoria realizados em seus prepostos, ainda que sejam apresentadas confirmações posteriores. A matriz preveria uma multa de R\$2.000,00 e um *fee* de 150% do valor da corretagem por ordem não apresentada. No caso de confirmações posteriores de ordem, aplicar-se-ia uma multa de R\$1.000,00 e *fee* de 50% do valor da corretagem por ordem. Ambas as penalidades seguiriam a relação da tabela abaixo, para o número de infrações verificadas:

Infração	Ausência de Ordem	Confirmação Posterior
1º apontamento	R\$2.000,00	R\$1.000,00
2º apontamento	R\$2.500,00	R\$1.500,00
3º apontamento	R\$3.000,00	R\$2.000,00
4º apontamento	R\$3.500,00	R\$2.500,00
5º apontamento	R\$4.000,00	R\$3.000,00

38. Nesse contexto, no qual a própria XP sanciona seus agentes autônomos de investimentos por ordem não apresentada, desde o 1º apontamento, esmorece a narrativa de que a Comissão de Valores Mobiliários deveria ser complacente com as falhas “pontuais” dos Acusados, destacadamente quando as irregularidades foram identificadas em prepostos já investigados pela BSM e por esta Autarquia pela ausência de ordens no âmbito do MRP. De todo modo, o percentual de ordens não registradas adequadamente e a confirmação posterior serão considerados na dosimetria da pena.

II.1 DO DIRETOR RESPONSÁVEL

39. A defesa alega que a extensão e a natureza da responsabilidade do diretor responsável não se confundem com a extensão e a natureza da responsabilidade da pessoa jurídica a que ele está vinculado. O entendimento de que a mera ocorrência de falhas é incapaz



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de motivar uma acusação se justificaria neste processo. Seria preciso considerar, concretamente, as medidas tomadas por aquela pessoa natural para cumprir os deveres que a regulação lhe atribui.

40. Neste ponto, tenho que as razões da defesa são corretas, mas não se aplicam ao presente caso. Com efeito, a criação de centros de imputação de responsabilidade é estratégia regulatória adotada pela CVM amplamente conhecida do mercado e sufragada de forma uníssona pela jurisprudência⁹ administrativa da Autarquia. Seu objetivo é evitar a diluição da responsabilidade no âmbito da pessoa jurídica e estimular a adoção de conduta diligente pelos administradores designados para ocupar certas funções, atribuindo-se a estes últimos a responsabilidade pelo cumprimento e fiscalização das normas legais e regulamentares¹⁰.

41. Nesse sentido, é o paradigma firmado no julgamento do PAS CVM nº RJ2010/9129, que trata da responsabilidade do diretor indicado pelo administrador de carteira pessoa jurídica como responsável perante a CVM, nos termos do art. 7º da Instrução CVM nº 306/99. Naquela assentada, asseverou-se:

"[a] lógica de se estabelecer focos de responsabilização – diretores responsáveis por atividades específicas – é a de criar não apenas centros de imputação de responsabilidades, de modo que estas não fiquem sempre diluídas na pessoa jurídica, mas, também a de, com isso, criar estímulos para a conduta diligente – ou protetiva – dos administradores designados para aquelas funções.

Assim, ainda que uma determinada instituição sempre tenha adotado más práticas, de maneira generalizada, **cabe ao diretor responsável registrar seus esforços, tomar medidas hábeis tanto a resolver os problemas existentes, quanto a delimitar sua responsabilidade.** E isso, vale dizer, é um dos elementos a diferenciar a responsabilidade de que aqui se está tratando de responsabilidade objetiva. Também não é de inversão do ônus da prova que se trata no presente caso, uma vez que a situação, de flagrante irregularidade, restou também comprovada.

Não há que se falar em injustiça, então, na atribuição de responsabilidade a uma única pessoa no caso vertente, mas, sim, no fruto de uma estratégia regulatória que sempre foi clara. E não há que se falar também, a meu ver, que, em casos como este, a responsabilidade deva caber, de forma exclusiva, à instituição administradora (...)" (grifou-se)

⁹ PAS CVM nº RJ2010/9129, Dir. Rel. Otávio Yazbek, julg. em 09.08.2011; PAS CVM nº RJ2010/13301, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. em 23.10.2012; PAS CVM nº 08/2004, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. em 06.12.2012; PAS CVM nº 03/2009, Dir. Rel. Ana Novaes, julg. em 30.04.2013; PAS CVM nº 01/2010, Dir. Rel. Roberto Tadeu, julg. em 09.07.2013; PAS CVM nº RJ2012/12201, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. em 04.08.2015; PAS CVM nº RJ2013/5456, Dir. Rel. Roberto Tadeu, julg. em 20.10.2015; PAS CVM nº 12/2013, Dir. Rel. Gustavo Borba, julg. em 24.05.2016; e PAS CVM nº RJ2016/6284, Dir. Rel. Pablo Renteria, julg. em 23.10.2018;

¹⁰ PAS CVM 19957.0003266/2017-90, Dir. Rel. Gustavo Borba, julg. em 10.04.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

42. No mesmo diapasão, vale reproduzir o seguinte trecho do voto proferido pela Diretora Relatora Luciana Dias no julgamento do PAS CVM nº RJ2010/13301:

“49. A construção desses núcleos de imputabilidade é uma estratégia legítima que visa a criar incentivos para que esses executivos construam, dentro das estruturas internas dos prestadores de serviços do mercado de valores mobiliários, redes de cumprimento e fiscalização das normas legais, regulamentares, proveniente da autorregulação ou mesmo as regras da própria instituição.

50. Essa estratégia está longe do instituto da responsabilidade objetiva, em que a avaliação da culpa ou do dolo do indivíduo é dispensável. O diretor responsável sempre pode comprovar que implementou mecanismos adequados para assegurar o cumprimento do mandamento legal ou regulamentar, que supervisionou com diligência, enfim, que promoveu esforços razoáveis para assegurar o cumprimento sistemático da regulação por aquela instituição e seus membros. Se esses mecanismos forem satisfatoriamente implementados e o diretor provou ser diligente, ainda que haja uma falha pontual, não há que se falar em responsabilidade do diretor responsável.”

43. Na mesma linha, mas ainda sem a construção teórica consolidada dos “centros de imputação de responsabilidade”, é a manifestação da então Diretora Relatora Maria Helena de Santana no PAS CVM nº RJ2005/8510:

“como diretor responsável, pessoa que existe na regulamentação exatamente para assegurar em nome da pessoa jurídica, que evidentemente não tem vontades, que as normas aplicáveis sejam por ela respeitadas, o diretor responsável só poderia ser eximido de culpa no caso em que ficasse demonstrado que ele tomou cuidados e providências para garantir o cumprimento dessas obrigações, que apesar de sua atuação não teriam sido seguidas.”

44. Assim, à luz dos precedentes desta CVM, deveria o Acusado ter demonstrado nos autos de que forma desincumbiu-se de suas responsabilidades, supervisionou com diligência ou promoveu esforços razoáveis para assegurar o cumprimento das normas estabelecidas pela ICVM 505/2011. Nesse caso, poder-se-ia concluir, em tese, que as falhas identificadas pela amostra da Inspeção ocorreram apesar da atuação do administrador.

45. Ocorre, entretanto, que, ao procurar demonstrar o seu empenho no aperfeiçoamento contínuo dos mecanismos de controle de registro de ordens e da estrutura de supervisão da XP Investimento, o Acusado refere-se unicamente a medidas tomadas após os fatos narrados pela Acusação. O desenvolvimento da ferramenta para envio e registro de ordens de cliente – o Trade Push – e a criação da XP Supervisão de AAI (“XPSA”) cronologicamente não demonstram que as irregularidades ocorreram a par dos melhores esforços do Acusado, restando, portanto,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

configurada a infração à luz do art. 4º da ICVM nº 505/11 e da jurisprudência consolidada desta Autarquia.

46. Nesse aspecto, é pertinente a lição do Diretor Pablo Renteria no julgamento do PAS CVM nº 2015/12087, julgado em 24.07.2018:

“Diferentemente do alegado pela defesa, a responsabilidade do diretor responsável não é objetiva nem solidária ao da sociedade gestora. Ao reverso, afigura-se pessoal e subjetiva, pois o diretor responde apenas nos limites da sua culpa, não sendo passível de punição caso reste demonstrado nos autos que tenha adotado as providências cabíveis para evitar a produção da irregularidade.”

47. Ademais, acresça-se especialmente ao presente caso que, após a controvérsia estabelecida nos autos do Processo Administrativo CVM nº RJ2013/0267, na qual foi salientada a falta de ordens gravadas no agente autônomo, os Acusados sequer poderiam alegar desconhecimento do possível baixo grau de aderência de seu preposto às normas das ICVM nº 505/11. Ao contrário, a XP exerceu papel ativo naquele processo administrativo e conhecia integralmente seu conteúdo.

48. Nesse quadro, ressoa absolutamente razoável exigir que o Acusado fosse capaz de minimamente demonstrar os esforços adicionais de conformidade em relação àquele agente autônomo, em especial, o que, reafirme-se, não restou demonstrado.

49. De fato, considerando que as irregularidades anteriormente encontradas na Guia da Bolsa datam do período compreendido entre 10.09.2010 e 02.05.2011 e que foram novamente encontradas na Inspeção de 2015, é improcedente a alegação de que a infração seria imperceptível para a administração da Acusada ou que denotaria mera falha pontual do preposto da XP atribuível objetivamente ou “por extensão” irrefletida ao diretor responsável.

III. CONCLUSÃO E PENALIDADES

50. Nesses termos, parece-me incontroverso que a XP e seu diretor responsável Guilherme Benchimol, cuja obrigação administrativa é direcionada nos termos do art. 4º da ICVM nº 505/11, não conseguiram manter a integridade dos registros de ordens transmitidas pelos clientes por meio da Guia de Bolsa, em violação aos arts. 12 e 13 da mesma instrução.

51. Na dosimetria da pena, entendo que o empenho dos Acusados no aprimoramento dos seus mecanismos de controle, consubstanciado nos autos na forma do Regulamento de Auditoria de Agente Autônomo de Investimentos e na apresentação da ferramenta *Trade Push*, conquanto não afaste a responsabilidade pela infração verificada, deve ser considerado como atenuante da penalidade a ser imposta. Tais aprimoramentos, ainda que posteriores às irregularidades verificadas pela Inspeção, demonstram os esforços empreendidos pelos Acusados para a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

conformidade de seus processos de trabalho, destacadamente em relação à atuação dos agentes autônomos, que exercem função essencial no modelo de negócios da XP.

52. Por outro lado, é necessário consignar a importância do registro prévio das ordens para a proteção dos investidores e manutenção da integridade do mercado. A toda evidência, não se trata aqui de mera burocracia ou custo de observância infundado. O registro prévio da ordem é demonstração de que a vontade inequívoca do cliente foi observada em determinada operação, traduzindo-se, dessa forma, em pressuposto para o bom funcionamento do mercado. Representa, ainda, importante instrumento de inibição de infrações graves como a gestão irregular de carteira, *insider trading*, operações com seguro, etc., conforme ampla jurisprudência desta Autarquia. O registro das ordens é também fundamental para a instrumentalização da reparação de danos pelos investidores, seja por meio do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos, de que trata o art. 77, da ICVM 461/07, seja em ação própria no âmbito do Poder Judiciário.

53. Nesse sentido, a atuação firme desta Comissão de Valores Mobiliários, em estreita coordenação com o autorregulador, aponta para o índice de convergência esperado dos participantes às regras de conformidade por ela estipulados.

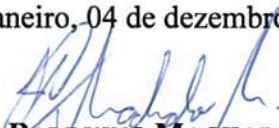
54. Por todo exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, com redação anterior a edição da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica do infrator, e como atenuantes os bons antecedentes, o percentual de ordens não registradas adequadamente, a confirmação posterior e os aprimoramentos dos mecanismos de controle, voto pela condenação de:

a) XP Investimentos CCTVM S.A. por infração ao artigo 12, parágrafo único, e ao artigo 13, *caput* e parágrafo único, da Instrução CVM nº 505, de 27 de setembro 2011, à penalidade de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

b) Guilherme Dias Fernandes Benchimol, na qualidade de diretor responsável, por infração ao artigo 12, parágrafo único, e ao artigo 13, *caput* e parágrafo único, da Instrução CVM nº 505, de 27 de setembro 2011, à penalidade de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

É o voto.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018.


HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.002587/2017-77

Reg. Col. nº 0968/18

Acusados: XP Investimentos CCTVM S.A.
Guilherme Dias Fernandes Benchimol

Assunto: Apurar responsabilidade por falhas no registro e arquivamento de ordens. Infração ao artigo 12, parágrafo único, e ao artigo 13, *caput* e parágrafo único, da Instrução CVM nº 505/2011.

Diretor Relator: Henrique Machado

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

I. UMA BREVE INTRODUÇÃO (QUE JÁ ANTECIPA A CONCLUSÃO)

1. Neste processo sancionador, julgamos se a XP¹ e seu diretor responsável, Guilherme Benchimol, devem ser responsabilizados por suposta infração ao artigo 12, parágrafo único, e ao artigo 13, *caput* e parágrafo único, ambos da Instrução CVM nº 505/2011.
2. A tese da Acusação se baseia na análise de um conjunto de 48 negócios realizados por 4 clientes da Corretora por meio de 2 sociedades de agentes autônomos de investimento. A SMI apurou falhas no registro e arquivamento de 7 ordens relativas a tais negócios, o que, na visão da área técnica, bastaria para configurar a violação aos artigos acima referidos.
3. Em 04.12.2018, o Colegiado deu início ao julgamento do caso com a leitura do voto do Diretor Relator, que acolheu a tese da Acusação e votou pela condenação dos acusados. Naquela ocasião, solicitei vista dos autos para melhor refletir acerca da responsabilidade das sociedades corretoras e de seus diretores responsáveis por problemas relacionados a falhas de registro e arquivamento de ordens de clientes atendidos por agentes autônomos de investimentos.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório elaborado pelo Diretor Relator.

4-5



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

4. Devolvo o processo após firmar convicção de que a Corretora e seu diretor responsável devem ser absolvidos das acusações que lhes foram formuladas.

5. No meu sentir, as obrigações de registro e arquivamento de ordens impostas pela Instrução CVM nº 505/2011 têm caráter instrumental e visam assegurar o adequado exercício da atividade de intermediação e prevenir os riscos a ela associados. Para seu cumprimento, a norma exige que os intermediários estabeleçam mecanismos efetivos de controle sobre as atividades que exercem; dessa forma, a princípio, só há que se falar em violação a essas obrigações na hipótese de a corretora não ter regras, controles e procedimentos ou caso eles não sejam efetivos. Em outras palavras, falhas pontuais e isoladas no registro e arquivamento de ordens não bastam para caracterizar a violação aos artigos 12 e 13 da Instrução CVM nº 505/2011.

6. Esse entendimento sobre como as obrigações de controle devem ser cumpridas pelos participantes do mercado e, consequentemente, como devem ser apurados os eventuais descumprimentos aos comandos normativos que as disciplinam, decorre de uma interpretação sistemática da Instrução CVM nº 505/2011, no sentido de que as obrigações previstas nos artigos 12 e 13 devem ser interpretadas à luz das diretrizes fixadas pelo artigo 3º daquele mesmo normativo. A interpretação, vale dizer, é corroborada pela forma como as obrigações de controle impostas aos participantes do mercado são ordinariamente supervisionadas, bem como pela melhor jurisprudência da CVM em casos sobre a matéria.

7. Por entender que os intermediários se desincumbem das obrigações de registro e arquivamento de ordens impostas pela Instrução CVM nº 505/2011 mediante a implementação de controles efetivos, julgo que a amostra coletada pela Acusação não foi suficiente para formar a convicção de que as falhas apontadas neste caso não eram pontuais e isoladas, revelando-se insubsistente, portanto, para condenar a Corretora e seu diretor responsável pela violação aos artigos 12 e 13 da Instrução CVM nº 505/2011, o que me leva a concluir pela absolvição.

8. Feito esse breve resumo, passo ao voto.

II. A FORMA COMO OS INTERMEDIÁRIOS CUMPREM AS OBRIGAÇÕES DE REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ORDENS DETERMINA O MODO PELO QUAL OS ALEGADOS DESCUMPRIMENTOS DEVEM SER APURADOS

O caráter instrumental das obrigações de registro e arquivamento de ordens

9. Inicialmente, vale pontuar que o registro e o arquivamento de ordens são imprescindíveis para o bom funcionamento do mercado. Como bem destacado no voto do Diretor Relator, “é

45



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

pressuposto do bom funcionamento do mercado de bolsa que toda operação executada seja precedida de ordem prévia por meio da qual o cliente manifesta ao intermediário sua vontade inequívoca de negociar determinado ativo em seu nome nas condições que especificar”.

10. As obrigações de registro e arquivamento de ordens servem a diversos objetivos, tais como garantir que as ordens dadas pelos clientes sejam adequadamente executadas e coibir a realização de práticas ilícitas, identificando o responsável pela emissão de ordens. Trata-se, portanto, de obrigações de controle, de caráter instrumental, que visam assegurar o adequado exercício da atividade de intermediação e prevenir os riscos a ela associados.

As obrigações de controle no sistema da Instrução CVM nº 505/2011

11. O cumprimento dessas obrigações se dá pelo estabelecimento de regras, procedimentos e controles internos efetivos, que permitam ao intermediário implementar e supervisionar o cumprimento da regulamentação do mercado de valores mobiliários, inclusive por parte de seus clientes. Nesse aspecto, quando das discussões que resultaram na edição da Instrução CVM nº 505/2011, destacou-se que:

“A importância dos intermediários na preservação da integridade do mercado é cada vez mais reconhecida pelos organismos internacionais. Para que eles desempenhem essa função, uma regulação eficiente do mercado de valores mobiliários deve induzi-los a estabelecer práticas operacionais capazes de cumprir a regulamentação em vigor e, ao mesmo tempo, prevenir irregularidades e ilícitos por parte dos participantes do mercado”².

12. Na minha leitura, o artigo 3º da Instrução CVM nº 505/2011 estabelece, em linhas gerais, como as obrigações de controle devem ser cumpridas pelos participantes do mercado e, também, as hipóteses em que tais obrigações restarão descumpridas. Além de exigir a adoção de regras, controles e procedimentos (*caput*) escritos, passíveis de verificação e disponíveis às entidades administradoras de mercados organizados (§1º), o artigo 3º explicita que as obrigações ali estabelecidas são consideradas descumpridas não só quando os controles forem inexistentes ou insuficientes, como também em casos de implementação inadequada (§2º), não se traduzindo em controles efetivos. O §3º daquele comando detalha serem “evidências de implementação inadequada das regras, procedimentos e controle internos”, “a reiterada ocorrência de falhas” (§3º,

² Edital de Audiência Pública nº 04/09, de 28.04.2009. Disponível em: http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2009/sdm0409.html.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

I) e “a ausência de registro da aplicação da metodologia, de forma consistente e passível de verificação” (§3º, II).

13. Essa interpretação é reforçada por uma análise sistemática dos dispositivos da Instrução CVM nº 505/2011 que cuidam de obrigações de controle de forma mais específica. Pode-se, por exemplo, cotejar a redação do artigo 12, parágrafo único, com a do artigo 13 daquele normativo. O primeiro comando, que cuida da obrigação de registro, faz referência a todas as ordens. Já o segundo, que cuida do arquivamento desses registros, não requer expressamente que todos os registros sejam arquivados. Não há razão para que as duas obrigações tenham alcances diferentes: parece-me, de fato, subentendido que a obrigação de arquivamento também abrange todas as ordens (cada qual objeto de um registro específico).

14. Outro exercício interessante é comparar o referido artigo 12 com o artigo 14 daquela mesma Instrução. O primeiro não faz referência expressa a sistemas, embora esteja claramente inserido no rol de obrigações instrumentais cujo cumprimento, insisto, se dá pela implementação de controles efetivos. Já o artigo 14 – que assim como o parágrafo único do artigo 12, também trata do registro de ordens, mas em um contexto mais específico (abrangendo apenas o registro daquelas transmitidas por telefone ou outro sistema de voz) – requer a manutenção de um *sistema de gravação*³. Parece-me implícito, portanto, que a obrigação de registro de ordens, genericamente prevista no artigo 12, também é cumprida com a adoção de sistemas efetivos.

15. A mesma conclusão pode, ainda, ser alcançada pelo exame sistemático do artigo 13 da Instrução CVM nº 505/2011, que trata da obrigação de arquivamento das ordens. O *caput* impõe ao intermediário a obrigação de “arquivar os registros das ordens transmitidas pelos clientes e as condições em que foram executadas, independentemente de sua forma de transmissão”. Não faz qualquer menção a sistemas, mas o parágrafo único, que o complementa, já se inicia com referência ao “sistema de arquivamento de que trata o *caput*”.

16. Todas essas análises, portanto, levam à constatação de que o eventual descumprimento das obrigações de controle impostas aos intermediários deve ser analisado à luz do que dispõe os §§2º e 3º do artigo 3º da Instrução CVM nº 505/2011. Assim, o fato de o parágrafo único do artigo 12 da Instrução CVM nº 505/2011 expressamente determinar que *todas* as ordens sejam registradas, não me parece autorizar a conclusão de que a ausência de registro de uma única ordem, ou de um

³ A própria Acusação, aliás, afirma que “a Instrução 505, em seus artigos 12 e 13, procura (...) também estabelecer um sistema de controle dos registros relevantes de modo a que seja possível a verificação, a qualquer momento, da compatibilidade entre ordens dadas e negócios executados” (§ 23 do Termo de Acusação).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

conjunto pouco expressivo de ordens, seja suficiente para a instauração de um processo sancionador, muito menos para a condenação dos intermediários. A interpretação literal, creio eu, peca por ignorar o sistema da Instrução CVM nº 505/2011 e a forma como os intermediários se desincumbem das suas obrigações de controle⁴.

A supervisão das obrigações de registro e arquivamento de ordens pela BSM

17. Essa interpretação é coerente com a forma pela qual as obrigações de registro e arquivamento de ordens são supervisionadas pelo autorregulador.

18. Em benefício da síntese, não irei aqui me estender no exame de como a regulação e autorregulação se articulam em nosso mercado de capitais: reporto-me, nesse ponto, ao que disse no Processo CVM nº SEI 19957.002928/2016-23, analisado em 10.07.2017, de minha relatoria⁵.

19. A Instrução CVM nº 461/2007 consagrou um modelo de autorregulação de monitoramento em nosso mercado de capitais, em que a “entidade autorreguladora exerce amplas competências regulatórias, submetendo-se, entretanto, ao controle prévio ou sucessivo exercido pelo Poder Público, conforme previsão legal ou regulamentar”⁶. Como explorei no precedente acima

⁴ Nem se argumente que essa perspectiva sistêmica ignora o caráter instrumental das obrigações de registro e arquivamento de ordens e deixa desprotegido os clientes do intermediário. De fato, a principal finalidade dessas obrigações é justamente garantir que as ordens dadas pelos clientes sejam adequadamente executadas e que os negócios decorram de ordens regularmente emanadas pelos clientes. Na perspectiva de proteção dos clientes, contudo, o regulador se vale de duas estratégias: o *enforcement* sobre as obrigações de controle impostas aos intermediários e a regulamentação das reclamações dirigidas ao Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (artigo 77 e seguintes da Instrução CVM nº 461/2007).

No âmbito do MRP, o autorregulador e a CVM (essa, em sede recursal) analisam eventuais falhas de registro ou arquivamento das ordens com uma perspectiva diferente. Naquele contexto, falhas têm consequências independentemente do seu caráter sistêmico. A falta de qualquer registro gera uma presunção relativa de que as operações não foram autorizadas pelo investidor, cabendo, portanto, o ressarcimento. Ou seja, um único negócio realizado em nome de investidor sem que a ordem tenha sido comprovada pelo intermediário pode gerar o dever de ressarcir o cliente, naturalmente desde que presentes os requisitos previstos no artigo 77 da Instrução CVM nº 461/2007.

Trata-se, penso eu, de olhares propositadamente diferentes e, de certo modo, complementares. No âmbito do processo administrativo sancionador, o que se analisa é se houve irregularidade administrativa punível. Nesse contexto, como regra geral, entende-se que falhas isoladas não significam necessariamente que os controles internos de uma instituição financeira são falhos ou que houve falta de diligência do diretor responsável da instituição. Já no contexto do MRP, a presunção relativa em favor do investidor decorrente da não apresentação do registro de determinada ordem se afigura como medida adequada e proporcional, garantindo a proteção dos investidores e a confiabilidade do sistema.

⁵ Recursos contra decisão da SMI – Procedimentos adotados pela BSM em instrução e julgamento de processo administrativo disciplinar.

⁶ BINENBOJM, Gustavo. *Poder de Polícia, Ordenação, Regulação*. 1ª Edição. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2016, p. 304.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

mencionado, a CVM supervisiona a atividade autorregulatória rotineiramente, com mecanismos de controle prévio e posterior.

20. Nesse contexto, as auditorias de rotina nos intermediários são preponderantemente realizadas pela BSM, por meio de auditorias operacionais. A SMI acompanha de perto a atuação do autorregulador, desde o planejamento das auditorias até a análise dos resultados nelas obtidos. Além das auditorias operacionais, que englobam 100% dos intermediários, a BSM realiza auditorias específicas, inclusive quando demandada pela área técnica da CVM.

21. Especificamente no tocante às obrigações de registro e arquivamento de ordens, a BSM, em conjunto com a CVM, fixa um patamar de tolerância máxima para a não apresentação de ordens, o qual, se observado, não sujeita o participante a medidas sancionadoras por parte do autorregulador⁷. A estipulação desse critério objetivo para determinar as medidas sancionatórias de *enforcement* deixa claro que, para tal finalidade, regulador e autorregulador entendem que as obrigações de controle impostas aos participantes do mercado devem, a princípio⁸, ser analisadas sob uma perspectiva sistêmica, sem prejuízo do entendimento de que para o bom funcionamento do mercado toda operação no mercado de bolsa executada em nome de cliente deve ser precedida por ordem prévia, como dispõe o normativo⁹.

Jurisprudência da CVM em casos envolvendo obrigações de controle

22. O entendimento de que as obrigações de controle impostas aos participantes do mercado devem ser analisadas sob uma perspectiva sistêmica é, ainda, corroborado pela jurisprudência da CVM em casos envolvendo obrigações de controle impostas não só aos intermediários¹⁰, como a

⁷ V. Ofício nº 27/2019/CVM/SMI/GMN, de 13.02.2019, e Comunicado Externo BSM 002/2019-DAR-BSM, de 15.02.2019.

⁸ A BSM ressalva que em determinadas situações – (i) reclamações ao MRP, (ii) investigações de denúncias e (iii) investigações de supervisão de operações e ofertas – pode haver adoção de medida sancionadora mesmo em casos em que a falha detectada é inferior ao patamar de tolerância máxima. V. Comunicado Externo BSM 002/2019-DAR-BSM. Trata-se, contudo, de hipóteses específicas, nas quais a ausência de ordens, de forma geral, é parte de um quadro maior e, portanto, o tamanho e o critério para definição de tais amostras é também diferenciado.

⁹ Por isso mesmo, a ausência de ordem abaixo da tolerância máxima não implica em ausência de apontamentos de auditoria e de exigência de plano de ação para regularização da não-conformidade. V. Comunicado Externo BSM 02/2017-DAR-BSM, de 21.12.2017.

¹⁰ PAS CVM nº SP2005/0180, j. em 04.07.2007, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcilio de Sousa; PAS CVM nº SP2010/049, j. em 12.11.2013, Dir. Rel. Otavio Yazbek.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

outros participantes do mercado¹¹, inclusive aqueles, como os administradores fiduciários, cuja regulação aplicável não contém comando similar ao artigo 3º da Instrução CVM nº 505/2011¹².

23. Um exemplo recente foi a decisão da CVM no PAS CVM nº RJ2016/295, j. em 07.05.2019, do qual fui relator. O caso foi instaurado para apurar responsabilidade de um administrador fiduciário e de um gestor de carteira por alegadas irregularidades na administração e gestão de fundos de investimento. Dentre outras imputações, o administrador fiduciário foi acusado de descumprir a regra que o obrigava a “diligenciar para que sejam mantidos, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem (...) os registros contábeis referentes às operações e ao patrimônio do fundo”, uma vez que havia se constatado falhas pontuais em lançamentos feitos na contabilidade de um dos fundos administrados. Por unanimidade, o Colegiado decidiu pela absolvição da administradora fiduciária dessa acusação, nos termos do voto:

“15. Ora, entendo não ser possível concluir, a partir de uma falha pontual em um registro contábil, rapidamente corrigida, que o administrador fiduciário não diligenciou para que os registros contábeis dos fundos que administra fossem mantidos atualizados e em perfeita ordem. O verbo empregado no comando – diligenciar – indica a meu ver que o dever do administrador fiduciário quanto a esse ponto constitui uma obrigação de meio.

16. Trata-se, a meu ver, da única interpretação que se coaduna à realidade da indústria de fundos brasileira. Afinal de contas, os administradores fiduciários – em especial aqueles que atuam em fundos com a carteira administrada por gestores independentes – são responsáveis pela contabilidade de muitos fundos e, consequentemente, pelo registro de uma enorme quantidade de operações.

17. Nessa perspectiva, apenar o administrador fiduciário por falhas isoladas na contabilidade de um fundo não só consolidaria uma visão irreal do que constitui uma conduta diligente nessas circunstâncias fáticas – e a diligência é um padrão abstrato de conduta, que necessariamente precisa ser analisada à luz das especificidades dos casos concretos – como também poderia acabar por produzir efeitos indesejados na indústria, seja afastando bons profissionais do mercado, seja encarecendo de forma descabida os seus serviços.

18. Não se trata, é bom que se diga, de consagrar um regime de irresponsabilidade. O dever de diligenciar para que os registros contábeis dos fundos sejam mantidos atualizados e em perfeita ordem requer que os administradores fiduciários implementem e mantenham sistemas e controles apropriados. No caso em tela, as explicações fornecidas pela Administradora Fiduciária evidenciam que essa possuía

¹¹ PAS CVM nº RJ2006/4663, j. em 04.09.2007, Dir. Rel. Marcos Barbosa Pinto; PAS CVM nº 2010/9129, j. em 09.08.2011, Dir. Rel. Otavio Yazbek.

¹² Por exemplo, o artigo 15, § 3º, I da Instrução CVM nº 542/2013, que dispõe sobre a prestação de serviços de custódia de valores mobiliários e o artigo 27, § 3º, I, da Instrução CVM nº 543/2013, que dispõe sobre a prestação de serviços de escrituração de valores mobiliários.

5-5



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

sistemas para gerenciar os lançamentos contábeis dos fundos administrados e que o problema aqui debatido decorreu, de fato, de uma falha isolada.”

24. O paralelo entre esse e aquele caso me parece evidente. Do mesmo modo que o intermediário deve cuidar para que *todas* as ordens sejam registradas, incumbe ao administrador fiduciário tomar providências para que *todos* os registros contábeis referentes às operações e ao patrimônio dos fundos de investimento que administra sejam mantidos atualizados e em perfeita ordem.

25. Em ambos os casos, o cumprimento das obrigações se dá pela implementação de sistemas e controles efetivos sobre as atividades desempenhadas. A CVM pode e deve exigir que os participantes do mercado adotem controles efetivos e estabeleçam rotinas para regularmente testar a eficácia desses procedimentos; não pode, contudo, presumir que tais controles, por melhores que possam ser, estejam 100% à prova de falhas. Como aponta a defesa, é possível, por exemplo, que uma ordem deixe de ser gravada por uma falha isolada no funcionamento dos equipamentos de gravação, fato que, por si só, a toda evidência, não autorizaria a conclusão de que o intermediário não tinha controles efetivos para cumprir com as obrigações de registro e arquivamento das ordens.

III. POR QUE AS PROVAS DOS AUTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO FORMULADA

26. Em razão da divergência sobre como as obrigações de controle devem ser cumpridas pelos participantes do mercado e, conseqüentemente, como devem ser apurados os eventuais descumprimentos aos comandos normativos que as disciplinam, dirijo também do Diretor Relator quanto à suficiência das provas trazidas pela Acusação.

27. Em que pese não ter se tratado de investigação por denúncia de supervisão por ausência de ordem, a amostra utilizada pela SMI foi bem limitada: considerou somente 2 sociedades de agentes autônomos (das mais de 424 à época vinculadas à XP), somente 48 negócios (dos mais de 20.439.909 realizados intermediados pela Corretora em 2015 para clientes de varejo) e somente 4 clientes (contra os mais de 120.000 clientes então ativos). A tabela a seguir resume a amostra que embasa a Acusação:

	Amostra SFI	Total 2015	%
Agentes autônomos	2	424	0,471698%
Negócios	48	20.439.909*	0,000235%
Clientes	4	120.000	0,003333%

* Considera apenas os negócios intermediados pela XP em 2015 para clientes de varejo.

47



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

28. Em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que a amostra colhida não nos permite concluir que os sistemas de registro e arquivamento de ordens da Corretora não eram efetivos, de acordo com os critérios do artigo 3º, §3º, da Instrução CVM nº 505/2011.

29. A inspeção realizada pela SFI foi solicitada no contexto de uma investigação para “apurar a existência de indícios de que agentes autônomos de investimentos vinculados à XP prestassem serviços de consultoria de valores mobiliários”¹³. Não se buscou, portanto, verificar irregularidades ou deficiências de controles e processos, mas examinar se duas sociedades de agentes autônomos de investimento estavam exercendo uma atividade regulada sem a devida autorização.

30. O próprio conceito de amostragem pressupõe que se considere a finalidade do procedimento e as características da população a ser analisada. No caso, o tamanho e a composição da amostra colhida pela área técnica, embora adequado para os fins a que originalmente se destinava, não é suficiente para sustentar eventual descumprimento dos artigos 12 e 13 da Instrução CVM nº 505/2011.

31. Também não me parece apropriado comparar o percentual de falhas da amostra colhida pela SFI com o limite de tolerância máxima para ausência de ordens empregado pela BSM para não adoção de medida sancionadora. O referido patamar é fixado com base no resultado das auditorias operacionais realizadas pelo autorregulador nos participantes, que seguem uma mesma metodologia e são, portanto, comparáveis entre si. Não é adequado, contudo, aplicá-la a outro tipo de amostra, obtida a partir de uma metodologia distinta¹⁴.

32. Diante de todos esses elementos, não vejo como formar convicção de que as falhas eram reiteradas ou sistemáticas a partir de uma amostra tão restrita, formatada fora de um contexto específico de investigação quanto à ausência de ordens e com adoção de metodologia diversa da utilizada em auditorias com cujo resultado se pretenda comparar, para fins de ponderação sobre o que efetivamente significa o percentual de falhas a que se chegou neste caso.

33. Ressalto, ainda, não haver elementos que indiquem que as falhas encontradas se inseriam em um quadro de irregularidade – ao contrário, as confirmações de ordens realizadas pelos clientes posteriormente aos respectivos negócios, ainda que não afastem a tipicidade formal da infração e

¹³ Item 2 do Termo de Acusação (doc. 0356875).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

sejam consideradas como meras atenuantes, demonstram que as referidas falhas não resultaram em prejuízos a clientes.

V. CONCLUSÃO

34. Diante de todo o exposto, voto pela absolvição dos Acusados.

35. Não posso, contudo, concluir este voto sem destacar que a proposta de absolvição, no caso concreto, não busca de modo algum colocar em xeque o importante trabalho que SMI e BSM fazem na supervisão dos controles adotados pelos intermediários. Pelo contrário.

36. Diante da crescente complexidade do mercado de valores mobiliários, a regulamentação dos participantes do mercado é cada vez mais baseada na imposição de obrigações de controle. A toda evidência, a CVM não se demite de suas responsabilidades ao exigir sistemas, controles e procedimentos efetivos que permitam aos participantes do mercado identificar, mensurar e mitigar os riscos associados às suas respectivas atividades. É fundamental que o regulador e o autorregulador incluam em suas rotinas de supervisão medidas destinadas a verificar a existência e eficácia dos sistemas, controles e procedimentos dos agentes regulados. O que se espera, portanto, é que os participantes do mercado trabalhem para a melhoria constante dos seus procedimentos e que a SMI e a BSM prossigam supervisionando esse trabalho.

É como voto.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2019

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor